

0023192-53.2018.8.26.0576

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... que o réu informou aos policiais que praticava o tráfico da droga em festas raves, que o dinheiro era proveniente do tráfico e que os rádios e celulares eram usados pelos vendedores para se comunicarem durante as festas.

Nos dizeres de Enrico Ferri, a rainha das provas é a lógica humana (FERRI, Enrico.

Discursos de acusação - ao lado das vítimas. São Paulo: Martin Claret, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, 1º andar - Centro

CEP: 15010-902 - São José do Rio Preto - SP

Telefone: (17)3233-6700 - E-mail: riopreto5cr@tjsp.jus.br

0023192-53.2018.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0023192-53.2018.8.26.0576

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

André Ricardo Alves dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA

Vistos.

ANDRÉ RICARDO ALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 04 de maio de 2018, por volta da 13h30min, na Rua James Moore, nº2090, Jardim Gisete, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Preto, o réu, após adquirir ou receber de indivíduo ainda não identificado, guardava, com o intuito de fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, 21,32 gramas de ecstasy, distribuídos em 55 comprimidos.

Acostados aos autos: auto de exibição e apreensão (fls. 07/08) e exame químico-toxicológico (fls. 18/20), exame pericial realizado em celular (fls. 452/460), ofício com resposta quanto à possibilidade de fornecimento de rastreamento de veículo (fls. 472/475), exame pericial de rádios comunicadores (fls. 504/506). Prisão preventiva decretada às fls. 61/62.

Diante da não localização do réu para ser notificado pessoalmente, foi realizada sua notificação editalícia (fls. 156 e 162).

O réu constituiu advogado e apresentou defesa preliminar (fls. 168/186).

A denúncia foi recebida em 10 de maio de 2019 (fls. 234/237) e o réu foi citado por edital (fls. 290).

Realizadas audiências de instrução, foram inquiridas as testemunhas de defesa Iuri, Nathanael, Rian, Evandro, Emerson e Eliezer; decretada a revelia do réu (fls. 298/300, 333/334 e 465/469).

Em memoriais e alegações finais, o Ministério Público requer a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 509/515).

A defesa requereu a conversão do julgamento em diligência, para oportunizar novamente ao réu o direito de prestar interrogatório, o que foi deferido.

Realizada nova audiência, o réu foi interrogado. O Ministério Público reiterou os memoriais anteriormente apresentados (fls. 526/529).

A defesa, em memoriais, alegou a nulidade do processo e imprestabilidade das provas em razão da invasão do domicílio do réu pelos policiais e por inobservância do direito ao silêncio; no mérito, requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de drogas (fls. 530/559).

É o relatório.

Decido.

Passo à análise das preliminares apresentadas pela defesa:

Descabida a alegação de nulidade por invasão do imóvel sem a devida autorização judicial. Isso porque os policiais agiram respaldados por elementos concretos, pois, conforme narrado pelos policiais, eles realizaram patrulhamento quando viram o réu em frente à residência e, ao perceber a presença da viatura, ele demonstrou nervosismo, assustou-se e tentou entrar para o interior do imóvel. No entanto, foi dada ordem legal de parada e ele obedeceu. Realizada revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado; ao ser indagado o motivo de ter tentado fugir, ele disse que tinha drogas ilícitas na casa, que não era ladrão nem tinha armas, mas tinha comprimidos de ecstasy, pois vendia em festas rave. André indicou o local onde a droga estava guardada e franqueou a entrada ao imóvel.

Logo, havia elementos concretos suficientes a indicar fundada suspeita da ocorrência flagrancial no interior do imóvel.

Nesse sentido, há tese fixada pelo STF:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/11/2015 (repercussão geral) (Info 806).

Assim, o ingresso regular da polícia no domicílio em caso de flagrante delito é válido diante da presença de fundadas razões (justa causa) que sinalizem a ocorrência de crime no interior da residência, afastando-se a tese defensiva (tese discutida no julgado paradigma - STJ. 6ª Turma. REsp 1.574.681-RS, Rel. Min.

Rogério Schietti Cruz, julgado em 20/4/2017, Info 606).

Também não há que se falar que violado o direito constitucional ao silêncio.

A priori, saliento que não há, no direito brasileiro, uma regra explícita sobre o chamado “Aviso de Miranda (advertência de Miranda, Miranda warning ou Miranda rights), originado do julgamento Miranda vs. Arizona, da Suprema Corte dos Estados Unidos (384 U.S 436, de 1966); todavia, o art. 5º, LXIII, CF dispõe que: o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Além do mais, serão consideradas ilícitas as provas obtidas a partir de declarações do preso sem prévia e formal advertência quanto ao direito ao silêncio (art. 157, CPP).” (COSTA, Klaus Negri; ARAÚJO, Fábio Roque. Processo Penal didático. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 65-66) Entretanto, para a caracterização da violação do direito ao silêncio e a não

autoincriminação é necessário que haja uma espécie de interrogatório “forçado” em que o investigado é obrigado a falar, sendo o investigado interrogado em ambiente intimidatório, o que diminuiu seu direito à não incriminação, o que não ocorreu nos autos.

Ademais, para o reconhecimento da nulidade em razão da falta de informação acerca do direito de permanecer em silêncio demanda a demonstração de prejuízo concreto, o que não é o caso do presente feito, já que a conclusão da conduta ilícita do réu é extraída de outros elementos de prova.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECEPÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. ADVERTÊNCIA SOBRE DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DENEGAÇÃO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Absolvição quanto ao crime do art. 311 do CP por ausência probatória. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, tendo em vista que essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano. 2. O afastamento da qualificadora concernente ao crime de estelionato, além de não encontrar respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal Justiça, demandaria necessariamente o revolvimento das provas dos autos, o que não se admite na via do estreita do writ. Precedentes. 3. Infringência ao princípio nemo tenetur se detegere. A jurisprudência dessa Corte Superior consolidou-se no sentido de que a falta de informação acerca do direito de permanecer em silêncio constitui nulidade relativa, que demanda a demonstração de prejuízo concreto para ser reconhecida, o que não é o caso do presente feito. Precedentes. 4. Tese de nulidade aventada somente em sede de embargos, sem qualquer menção ao pleito em momentos processuais antecedentes – defesa prévia, instrução, alegações finais e apelação –, restando obstada pela operação do instituto da preclusão. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido., ressaltei (STJ, AgRg no Habeas Corpus nº 472.683 – SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 04/02/2020)

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime de tráfico restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), pelo exame químico-toxicológico (fls. 18/20), bem como as provas colacionadas nos autos.

A autoria também é certa.

O réu, na fase policial (34/35), bem como em juízo (fls. 529), narrou que na data dos fatos saiu do trabalho por volta de meio-dia, com o veículo da empresa, passou em um restaurante para almoçar e na sequência, foi para sua casa. Estava descansando no sofá quando chegaram policiais militares e entraram em sua residência à procura de drogas. Disse que os policiais encontraram 55 comprimidos de ecstasy guardados em seu armário além de dinheiro, dois aparelhos celulares e três rádios comunicadores. Alegou que a droga era para seu consumo pessoal, negando a traficância, dizendo que comprava os comprimidos pela internet (deep web), e comprou esta quantidade porque é mais barato do que comprar individualmente. Disse que o dinheiro era proveniente da venda de uma moto que estava em nome de sua mãe, alegando que vendeu a motocicleta para um amigo chamado Riran. Alegou que possuía rádios comunicadoras porque fez uma viagem para a Bahia com alguns amigos e usavam os rádios para se comunicarem. Alegou que um dos celulares apreendidos era seu e o outro pertencia à empresa Cantoia e Figueiredo, para a qual trabalhava. Afirmou que foi condenado anteriormente por tráfico, porque foi surpreendido transportando seis quilos de maconha.

Em juízo, novamente alegou que a droga apreendida era para seu consumo pessoal, afirmando que comprou a droga pela deep web e pagou cerca de R\$ 4,00 a R\$5,00 a unidade e que comprou aquela quantidade para economizar. Disse que pagou pela droga em dinheiro, via depósito bancário. Afirmou que atualmente é ajudante de pintor; à época dos fatos era técnico de instalação da empresa Net, ganhava cerca de R\$ 2.000,00 a R\$ 2.500,00 por mês. Alegou que os policiais apreenderam R\$ 5.000,00 em sua residência, e não apenas R\$ 3.000,00 como alegado por eles e que o dinheiro era

oriundo da venda de uma motocicleta, que vendeu uma semana antes da abordagem para Riran, afirmando que a motocicleta estava no nome de sua mãe; disse que os rádios comunicadores apreendidos, comprou para ser usado em um festival de música eletrônica, no final do ano de 20017, início de 2018, que foi no Estado da Bahia com alguns amigos. Alegou que foi abordado no horário do almoço e quando estava saindo de casa para retornar ao trabalho, foi surpreendido por policiais militares já dentro de sua casa; alegou que os policiais reviraram a casa e encontraram a droga no guarda-roupa dele.

Os policiais militares Evandro e Luis Henrique, na fase policial (fls. 04/06 e 30), bem como Evandro em juízo (fls. 334), narraram que na data dos fatos realizaram patrulhamento pelo bairro Jardim Gisete quando viram o réu em frente à residência localizada na Rua James Moores, 2090, sendo certo que ao perceber a presença da viatura, ele demonstrou nervosismo, assustou-se e tentou entrar no imóvel. No entanto, foi dada ordem legal de parada e ele obedeceu. Realizada revista pessoal nada de ilícito foi encontrado; ao ser indagado o motivo de ter tentado fugir, ele disse que tinha drogas ilícitas na casa, que não era ladrão nem tinha armas, mas tinha comprimidos de ecstasy, pois vendia em festas rave. André indicou o local onde a droga estava guardada e franqueou a entrada ao imóvel. Narraram que foram até o local indicado pelo réu, uma gaveta de seu guarda-roupa, onde encontraram 55 comprimidos de ecstasy e R\$ 3.053,00 em notas diversas, que o réu informou se tratar de dinheiro proveniente da venda de drogas. Informaram que encontraram três rádios comunicadores e dois aparelhos de telefones celulares na sala, os quais seriam usados durante as festas para comunicação entre os vendedores, porém o réu não informou quem seriam tais pessoas.

Em juízo, o policial Evandro (fls. 334), esclareceu que o réu correu ao ver a viatura policial e por isso correram atrás dele, sendo que o abordaram na residência. Disse que lhe foi garantido o direito ao silêncio. Acrescentou que na residência havia alguns amigos do réu em pontos diversos da casa, não sendo encontrado nada de ilícito com eles. Afirmou que há orientação quanto à assinatura do tablet, não sendo obrigatório, bem como que o réu assinou no campo de assinatura. Afirmou que não é comum apreender rádios comunicadores em São José do Rio Preto.

O policial Emerson, ouvido em juízo, afirmou que quando o réu viu a viatura policial, ele correu para o interior da residência, o que ensejou a sua abordagem, que ocorreu na garagem da casa; não se recorda se foi apreendido alguma coisa em poder do réu porque era motorista da viatura e nela permaneceu, mas se recorda que no interior da residência foram apreendidos comprimidos de ecstasy, sendo afirmado pelo réu que ele possuía tais comprimidos para venda, dizendo que vendia em festas raves, bem como que ele tinha dívidas decorrentes do tráfico. Disse que o réu foi conduzido até a central de flagrantes, mas foi liberado porque nesta cidade não tem laboratório que faz a identificação dessa espécie de substância entorpecente, sendo necessário encaminhar a substância para ser analisada em São Paulo. Disse que somente o réu foi abordado. Afirmou que também foi apreendido dinheiro, que o réu disse que era proveniente do tráfico. Não se recorda se o réu comentou ter vendido uma motocicleta na época dos fatos. Afirmou que o campo "pessoa qualificada" constante no documento de fls. 266 é destinado para assinatura do autuado. Disse que enquanto o réu foi conduzido para o plantão policial, ele conversou com os demais policiais e confessou que vendia a droga em festas raves, bem como que havia dívidas de outros tráficos, realizado no Estado do Mato Grosso, salvo engano.

O policial Elieser, ouvido em juízo, afirmou que não se recorda dos fatos em razão do tempo decorrido; pelo que se recorda quem apresentou a ocorrência foram os policiais Evandro e Luis Henrique, enquanto ele permaneceu na viatura enquanto os policiais mencionados realizaram a abordagem do réu.

Conforme exposto, pela dinâmica dos fatos narrados pelos policiais não há dúvida de que as drogas encontradas com o réu se destinavam ao comércio e não a seu uso exclusivo, como alegado.

Nesta esteira, temos inicialmente a atuação policial em razão de atitude suspeita do réu, já que ao perceber a aproximação policial, demonstrou nervosismo e correu para a residência. No interior da residência do réu, os policiais apreenderam 55

comprimidos de ecstasy, R\$ 3.053,00, dois aparelhos celulares e três rádios comunicadores, sendo certo que o réu informou aos policiais que praticava o tráfico da droga em festas raves, que o dinheiro era proveniente do tráfico e que os rádios e celulares eram usados pelos vendedores para se comunicarem durante as festas. Nos dizeres de Enrico Ferri, a rainha das provas é a lógica humana (FERRI, Enrico. Discursos de acusação – ao lado das vítimas. São Paulo: Martin Claret, 2005, p. 175).

Ainda nesse sentido, Kazuo Watanabe preceitua que:

(...) a cognição é prevalentemente um ato de inteligência, consistente em considerar, analisar e valorar as alegações e as provas produzidas pelas partes, vale dizer, as questões de fato e as de direito que são deduzidas no processo e cujo resultado é o alicerce, o fundamento do iudicium, do julgamento do objeto litigioso do processo. (WATANABE, Kazuo. Da Cognição no Processo Civil. Campinas: Bookseller, 2000, p.58-59).

Analisando as circunstâncias fáticas, evidencia-se pela lógica que as drogas se destinavam a fornecimento a terceiras pessoas, e não uso próprio; prova disso é a quantidade de porções individuais apreendidas, totalizando 55 comprimidos, quantidade considerável e, em regra, superior ao uso diário, o que reforça a conclusão de que o entorpecente se destinava ao comércio.

Da mesma forma, o dinheiro encontrado em seu poder também corrobora a conclusão de que já havia vendido algumas porções.

Assim a negativa do réu, pueril, não convence, até porque não apontou qualquer motivo razoável para que os policiais o incriminassem leviana e gratuitamente. Os policiais são funcionários públicos têm responsabilidade funcional com seus superiores, com a Justiça, com a sociedade e com suas famílias. Não se crê que policiais saiam em diligências portando drogas para intrujar em pessoa que sequer conhece, sob o sério risco de responsabilização pessoal e funcional, de perder seu trabalho, sem qualquer motivo sério e razoável. Até porque o próprio réu afirmou que não conhecia os policiais responsáveis pela ocorrência.

Por fim, a versão dos policiais é amparada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial acostado nos autos, que comprova a apreensão da droga mencionada.

No mais a alegação do réu de que o dinheiro apreendido era proveniente da venda de sua motocicleta não prospera. Isso porque apesar da testemunha Riran, na fase policial (fls. 32/33), bem como em juízo (fls. 334), afirmar que comprou uma motocicleta do réu pelo valor de R\$4.500,00 dois dias antes da prisão dele, o réu ou a testemunha não trouxeram aos autos qualquer documento que comprovasse que a motocicleta era de propriedade do réu anteriormente.

Por fim, as testemunhas arroladas pela defesa não trouxeram qualquer elemento capaz de influir no julgamento do feito.

Nesse sentido, a testemunha Iuri, primo do réu, em juízo (fls. 300), disse não saber se o réu usa ou vende drogas, tampouco sabe qual sua profissão ou trabalho. Alegou que em certo dia estava na companhia de seu irmão na pastelaria quando policiais os abordaram e disseram que seu irmão era muito parecido com uma pessoa que eles estavam procurando, sem dizer de quem se tratava. Na sequência, os policiais o conduziram até sua casa junto com seu irmão, e revistaram toda a casa. Alegou que realmente seu irmão se parece com o réu, mas ele e o irmão não sabiam que era o réu que os policiais estavam procurando.

A testemunha Nathanael (fls. 300), declarou que não conhece o réu. Alegou que é inquilino da casa em que o réu morava e no começo do ano de 2019, policiais invadiram sua casa estourando o cadeado e bateram na janela gritando para que a abrisse, assustando sua esposa grávida de 06 meses na época. Disse que abriu e um policiais mostrou um papel enrolado, dizendo ser um mandado, mas não mostrou o conteúdo do papel e pediram seus documentos, enquanto outros dois policiais pediam para sua esposa abrir a porta da residência. Ao final pediram desculpa e foram embora.

Desta forma, comprovada a autoria e materialidade, de rigor a condenação do réu. Passo a dosar a pena:

Sopesando as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, observo que não estão presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis capazes de exasperar a pena nesta fase. Assim, a pena-base é fixada em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal.

Na segunda fase, em razão da reincidência específica (processo 0004890-27.2014.8.12.0019, fls. 498), a pena sofre acréscimo de um sexto, sendo fixada em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal.

Na terceira fase não incide a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, em razão da reincidência específica do réu.

À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. Fixo o regime fechado para o cumprimento da pena privativa, considerando a quantidade de pena aplicada e a reincidência do réu, nos termos do artigo 33, do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 44, do CP, notadamente em face da quantidade de pena aplicada e da reincidência do réu e, ainda, pela inconciliabilidade com a determinação de cumprimento inicial da pena em regime fechado.

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu ANDRÉ RICARDO ALVES DOS SANTOS às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Mantenho a prisão preventiva decretada em desfavor do réu, uma vez que a prisão cautelar permanece necessária para a garantia da Ordem Pública e da aplicação da Lei Penal, sendo insuficientes as demais cautelares trazidas pela Lei n. 12.403/11. Fica decretada ainda, a perda dos rádios comunicadores, celulares (utilizados para a prática do tráfico) e valores apreendidos (fruto do tráfico), nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06 (fls. 07/08).

Condeno o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C..

São José do Rio Preto, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA